

1502154-82.2019.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... fachada que, na verdade, era ponto de tráfico de entorpecentes), e os péssimos antecedentes criminais, circunstâncias concretas obstativas da aplicação da referida minorante. 8. Ordem denegada." (STF HC 111.666/MG Rel. Min. Luiz Fux j. 08.05.12 DJU 23.05.12).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS.

LIBERDADE PROVISÓRIA: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502154-82.2019.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502154-82.2019.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS PEREIRA DE MENESES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

MATEUS PEREIRA DE MENESES foi denunciado por incursão no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 28 de outubro de 2019, por volta das 21h30, na Avenida Eugênio Negri - Viela Seleni - Jardim Zaira, nesta cidade e comarca, o acusado guardava, trazia consigo e expunha à venda, para entrega a consumo de terceiros, as substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica descritas no auto de exibição e apreensão (fls. 8-9) e laudo de constatação (fls. 11-4), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Recebida a denúncia, o réu foi citado (fl. 145) e apresentou resposta à acusação.

Durante a instrução, as testemunhas arroladas pelas partes foram devidamente inquiridas. Decretou-se a revelia do réu (fl. 181).

Em memoriais finais, o Ministério Público requer a procedência da ação penal, enquanto a Defesa suscita a nulidade da instrução por ofensa ao § 14 do art. 28-A do Código de Processo Penal. No mérito, busca a absolvição por insuficiência de provas ou, ao menos, a fixação da pena no patamar mínimo, reconhecendo-se a menoridade relativa e o tráfico privilegiado, sob regime penitenciário inicial aberto, além da substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

Malgrado o esforço argumentativo da Defensoria Pública, a preliminar levantada não se sustenta. A questão atinente ao acordo de não persecução penal já foi devidamente afastada no momento oportuno, destacando-se a falta de requisito objetivo (fls.160-6).

No mérito, a acusação procede.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 05-7), auto de exibição e apreensão (fls. 08-9), laudo de constatação (fls. 11-4), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 49-51), laudo da bolsa apreendida (fls. 60-1) e prova oral colhida.

Comprovou-se a autoria.

Interrogado, em solo policial, o réu manteve-se em silêncio (fl. 04). Em juízo, apesar de intimado, não compareceu para interrogatório (fl. 181).

Os policiais militares, na fase administrativa, historiaram que (sic) “estávamos em patrulhamento pela rua Eugênio Negri, Jd. Zaira, quando incursionamos pela Viela Selene, local conhecido pela traficância de drogas, onde nos deparamos com três sujeitos em atitude suspeita, sendo que um deles estava com uma pochete na mão. 2 (dois) suspeitos fugiram correndo, sendo abordado apenas o que estava com a pochete, o qual foi identificado como Mateus. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em suas vestes. Contudo, no interior da pochete havia 28 (vinte e oito) pinos contendo substância semelhante ao crack e 11 (onze) trouxinhas contendo substância semelhante a maconha. Indagado sobre os fatos, o suspeito confessou voluntariamente estar traficando drogas no local há uma semana, mas não deu maiores detalhes sobre o crime” (fls. 02-3).

Sob o contraditório, o policial militar Jacson reiterou integralmente a dinâmica do ocorrido e confirmou que o réu foi visto em local conhecido como ponto de venda de drogas com uma bolsa vermelha nas mãos, na qual as drogas foram apreendidas. Informalmente, o réu confessou a narcotraficância e acrescentou que já atuava no tráfico há uma semana (mídia digital).

No mesmo sentido as declarações do policial militar Sérgio (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de policiais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial. Nessa linha:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório,

portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07).

Observe-se que os depoimentos prestados em juízo pelos policiais, além de plenamente coerentes, estão em perfeita harmonia àqueles por eles prestados perante a autoridade policial. Ademais, não há qualquer motivo a que não possa ser atribuído total crédito a tais depoimentos. Não há nos autos prova alguma, sequer indícios, de que os policiais tivessem motivo particular, injusto, para incriminar falsamente o réu.

Descabida a alegação da Defesa quanto à ilegalidade na busca pessoal, uma vez que os policiais responsáveis pela abordagem afirmaram ter visualizado o réu, em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, na companhia de outros dois indivíduos e com uma bolsa nas mãos. Não bastasse, o acusado e os demais indivíduos correram com a aproximação dos policiais. Assim, havia fundadas razões para a busca pessoal.

Além disso, a quantidade de droga encontrada e as demais circunstâncias da apreensão, tais como a variedade e a forma em que era transportada, além do local da abordagem, conhecido como ponto de tráfico, trazem elementos suficientes de que o réu tinha a droga para entrega a terceiros.

Dessa forma, entendo que o delito de tráfico de drogas está fartamente comprovado.

Passo à fixação da pena.

Atendendo aos ditames do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal, fixa-se a pena base no patamar mínimo, qual seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda etapa, a atenuante da menoridade relativa não enseja redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, não deve incidir a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Restou demonstrado que o réu transportava entorpecentes de espécies diversas, em local conhecido como ponto de venda de drogas, não comprovou o exercício de atividade lícita, além de informalmente informar aos policiais que já praticava o tráfico no local há uma semana, a indicar um acentuado envolvimento no comércio de entorpecentes, ou seja, a não ocasionalidade da conduta. Nessa direção:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. ANÁLISE DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA OU DE SER INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADES NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DENEGADA. 1. A causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da lei 11.343/06 está condicionada ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. [...] 3. A conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza do entorpecente, os apetrechos utilizados e as circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes: RHC 94.806/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/04/2010; HC 116.541/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/6/2013; HC 98.366/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira

Turma, DJe de 5/2/2010. [...] (STF HC 121.057/SP Rel. Min. Luiz Fux j. 25.02.14 DJU 18.03.14).

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA, MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PRESUNÇÃO HOMINIS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS. APTIDÃO PARA LASTREAR DECRETO CONDENATÓRIO. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REAPRECIÇÃO DE PROVAS. DESCABIMENTO NA VIA ELEITA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06, ANTE A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA. 1. O §4º do artigo 33 da Lei de Entorpecentes dispõe a respeito da causa de diminuição da pena nas frações de 1/6 a 2/3 e arrola os requisitos necessários para tanto: primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividades criminosas e não à organização criminosa. 2. Consectariamente, ainda que se tratasse de presunção de que o paciente é dedicado à atividade criminosa, esse elemento probatório seria passível de ser utilizado mercê de, como visto, haver elementos fáticos conducentes a conclusão de que o paciente era dado à atividade delituosa. 3. O princípio processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de presunções 'hominis' ou 'facti', pelo juiz, para decidir sobre a procedência do 'ius puniendi', máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo-a no art. 239 como 'a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias'. Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162). Precedente (HC 96062, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336). 4. Deveras, o julgador pode, mediante um fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal, utilizando raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da conduta. 5. A criminalidade dedicada ao tráfico de drogas organiza-se em sistema altamente complexo, motivo pelo qual a exigência de prova direta da dedicação a esse tipo de atividade, além de violar o sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta Magna, praticamente impossibilita a efetividade da repressão a essa espécie delitiva. 6. O juízo de origem procedeu a atividade intelectual irrepreensível, porquanto a apreensão de grande quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas, sendo certo que, além disso, outras circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. 7. In casu, o Juízo de origem ponderou a quantidade e a variedade das drogas apreendidas (1,82g de cocaína pura, 8,35g de crack e 20,18g de maconha), destacando a forma como estavam acondicionadas, o local em que o paciente foi preso em flagrante (bar de fachada que, na verdade, era ponto de tráfico de entorpecentes), e os péssimos antecedentes criminais, circunstâncias concretas obstativas da aplicação da referida minorante. 8. Ordem denegada." (STF HC 111.666/MG Rel. Min. Luiz Fux j. 08.05.12 DJU 23.05.12).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA: INADMISSIBILIDADE. DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO VOLTADA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06 E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA: IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. [...] 6. Os fatos que deram ensejo à não aplicação da causa de diminuição de pena prevista na Lei de Tóxicos são hígidos e suficientes para atestar a dedicação do Paciente às atividades criminosas. 7. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas. [...] (STF HC 109.236/SP Rel. Min. Cármen Lúcia j. 13.12.11 DJU 14.23.12).

EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRIVILÉGIO, REGIME DIVERSO

DO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. Acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso defensivo para fixar a pena-base em seu patamar mínimo e, por maioria de votos, deu provimento ao recurso ministerial, para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, majorando as penas do embargante para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, e fixar o regime inicial fechado, vencido em parte o E. Des. Ricardo Sale Júnior, que negava provimento ao recurso acusatório, mantendo o redutor e regime semiaberto, aplicados em primeiro grau. Maioria que considera imperativo o afastamento do redutor, pelas circunstâncias em que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes foi praticado - quantidade e variedade considerável de entorpecentes (16 porções de cocaína, na forma de crack, com massa de 49,7 gramas; e 02 porções de maconha, pesando 41,7 gramas pesos líquidos, cf. laudos de fls. 16/17 ou 53/54 e 89/91), além de dinheiro - circunstâncias concretas que indicam que o apelado já gozava da confiança na cadeia da traficância para, com habitualidade, executar este tipo de tarefa. Regime inicial de cumprimento de pena fechado imperativo, ante a gravidade concreta do delito praticado, com vistas principalmente à repressão e à prevenção delitiva e resguardo da tutela social, ao menos no início do cumprimento da pena privativa de liberdade, tal como decidiu a douta Turma Julgadora, por maioria de votos. Embargos infringentes rejeitados. (TJSP; Embargos Infringentes e de Nulidade 0000079-92.2017.8.26.0580; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Assis - 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 19/05/2021; Data de Registro: 19/05/2021 - grifo nosso).

APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas - Confissão do acusado - Falas dos policiais firmes e coerentes - Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo conjunto probatório - Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o réu - Traficância comprovada - Condenação era de rigor - Causa de aumento comprovada - Penas bem dosadas - Privilégio do art. 33, § 4º, da LD - Não cabimento - Regime inicial fechado mantido - Substituição da pena corporal por restritivas de direitos - Impossibilidade - Sentença mantida - Recurso defensivo desprovido. [...] No presente caso, o réu possuía quase 100 porções de drogas variadas, dentre elas, cocaína e crack, entorpecentes de elevado potencial lesivo, demonstrando seu envolvimento na atividade criminosa. Ademais, não comprovou ocupação lícita, e confirmou que já atuava na venda ilegal havia um mês. Portanto, à luz das peculiaridades do caso em tela, em que pese a primariedade do réu, é inegável que as circunstâncias concretas do delito praticado impedem a aplicação do §4º, do artigo 33, da lei 11.343/06. Frise-se que mencionado parágrafo 4º emprega o termo "poderão", o que seguramente indica não ser obrigatória a redução. [...] (TJSP; Apelação Criminal 1501589-14.2020.8.26.0628; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Embu das Artes - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 16/05/2022; Data de Registro: 16/05/2022 - grifo nosso).

Define-se, assim, a condenação em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

O valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do acusado.

Registre-se que o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 44 da Lei 11.343/06, nas partes em que se vedava a concessão de liberdade provisória (HC n. 104.339, rel. Min. Gilmar Mendes) e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (HC n. 97.256, rel. Min. Ayres Britto), bem como do parágrafo 1º do art. 2º da Lei n. 8072/90, que impunha o regime inicial fechado (HC n 111.849, rel. Min. Dias Toffoli).

Todavia, a gravidade in concreto do delito, considerando o alto potencial lesivo do

"crack" para saúde pública, indica um grau acentuado de culpabilidade, de forma que o regime inicial fechado mostra-se necessário para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM DENEGADA. Possibilidade de fixar regime inicial fechado e de afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. Precedentes. Ordem denegada." (STF - HC 119.515/AC - Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 03.12. - DJU 10.12.13)

Sobre o potencial lesivo da quantidade de "crack" apreendida:

"A cocaína pode produzir uma intoxicação grave e por vezes inesperadamente com pequenas doses. A dose letal pode estar entre 0,8 a 1,2 g para um homem de 70 kg. No entanto, fumadores de base livre reportam uso de quantidades que excedem a 1 g. Em contrapartida, há casos em que se pode ocorrer o óbito com uma dose extremamente baixa de 20 mg. Isto pode ser explicado pela ocorrência da tolerância reversa que se caracteriza ou pelo aumento da susceptibilidade ao aparecimento de convulsões em doses consideradas recreacionais ou por uma excitação aumentada obtida em doses menores em usuários crônicos, fato que pode ser explicado pela diminuição da biossíntese dos neurotransmissores, o que leva a uma potencialização dos efeitos excitatórios." (Passagli, Marcos; Toxicologia Forense - Teoria e Prática, 5ª ed., Millennium: Campinas, 2018 - pg. 180-1).

Pelo mesmo motivo, não é hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, insuficiente para prevenção e reprovação da conduta.

Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal para CONDENAR o réu MATEUS PEREIRA DE MENESES, qualificado nos autos, a cumprir pena de 05 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e a pagar 500 dias-multa, no patamar mínimo, por incursão no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Faculta-se ao réu o apelo em liberdade.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e oficie-se para a destruição da contraprova das drogas e da bolsa apreendidas (fls. 08-9), nos termos dos arts. 63 e 72 da Lei n.º 11.343/2006.

Defere-se os benefícios da justiça gratuita ao réu.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella - Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA